

1501878-95.2022.8.26.0071

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Favorecimento real

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/11/2022

... de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501878-95.2022.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501878-95.2022.8.26.0071

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Favorecimento real

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3019638/2022 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-BAURU, 23634118 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-BAURU

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDSON HENRIQUE DIAS DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

EDSON HENRIQUE DIAS DOS SANTOS foi dado como incurso nas penas do art. 349-A do Código Penal, porque, no dia 03 de janeiro de 2.022, por volta das 16h30, no Centro de Progressão Penitenciária I de Bauru, nesta cidade, ingressou com dois aparelhos celulares e uma placa de aparelho celular, sem autorização legal.

O réu foi citado (fls. 94).

Em audiência realizada em 20 de outubro de 2.022, após apresentação de defesa preliminar, a denúncia foi recebida. Na mesma oportunidade, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 103 - audiovisual).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 106/108).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 113/117, alegando que: 1)- a perícia

constatou que os aparelhos não estavam em funcionamento; 2)- interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime; 3)- a hipótese é de crime impossível, pois todos os presos que retornam à unidade são submetidos a detector de metais e scanner corporal; 4)- o réu agiu sob coação moral irresistível. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão; o reconhecimento da tentativa e a fixação do regime inicial aberto.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls. 05/06, pelo auto de apreensão de fls. 07 (dois mini aparelhos de celular da marca L8star e uma placa de mini aparelho celular) e pelo laudo pericial de fls. 48/53.

A autoria deriva da prova oral e deve ser atribuída ao acusado.

Em juízo, a testemunha Rodrigo Silvério Guaranha, agente de segurança penitenciária, afirmou que o acusado voltava da saída temporária e foi submetido ao aparelho de body scanner. Constatou-se, então, imagem suspeita no interior de seu abdômen. O réu foi colocado em uma cela temporária na portaria e, após, conduzido para a cela da enfermaria. Indagado, ele confessou que engoliu telefones celulares e uma placa de celular para introduzi-los na unidade prisional. De livre e espontânea vontade, o réu expeliu os objetos. Não sabe por qual via ele os expeliu. O acusado somente entregou os celulares, sem que fosse visto expelindo-os. Ele foi submetido novamente ao aparelho de scanner, tendo sido constatado que mais nada trazia em seu corpo. Até expelir os objetos, o réu ficou isolado em uma cela da enfermaria.

A testemunha Fabio Luiz Montanher Dadamos, também agente de segurança penitenciária, relatou que o réu retornava da saída temporária e tentou ingressar na unidade prisional com dois aparelhos celulares e uma placa de celular. Ele foi submetido ao body scanner no setor de portaria. Após detecção da imagem, o acusado, tido então como suspeito, foi conduzido ao setor de enfermaria. Após alguns dias, ele expeliu aqueles objetos. Foi feito o comunicado de evento e a ocorrência foi registrada na delegacia. O acusado ficou isolado até expelir o material, em cela do setor de enfermaria. Após expelir os equipamentos, ele foi submetido novamente ao scanner para constatar que não trazia mais objetos no corpo. Tal procedimento é de praxe na troca de plantões com os presos que estão isolados e são suspeitos de trazer objetos ilícitos. Eles são encaminhados pela manhã ao setor de portaria, para tal fim. Após, levam-se os presos para as celas, que também são verificadas. Interrogado em juízo, o réu declarou ter sido obrigado a levar os telefones para dentro da unidade, pois devia para um traficante que também estava detido ali. O traficante o ameaçou, dizendo que, se não levasse os mini-telefones, iria quebrar seus dois braços e suas duas pernas, bem como jogá-lo na gaiola. Ficou com medo e levou os telefones. Devia R\$ 850,00. Tratava-se de dívida de maconha, que foi contraída em um mês e três dias. Consumiu 85 gramas. Estava no Centro de Progressão Penitenciária I de Bauru há quase um ano. Antes do período em que contraiu a dívida, adquiria drogas através da ajuda de sua esposa. Posteriormente, ela não conseguiu mais ajudá-lo, pois sofreu um AVC e um derrame cerebral. Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu admitiu ao menos que entrou no estabelecimento prisional trazendo em seu corpo itens cujo ingresso no local era proibido.

Não bastasse, segundo depoimentos insuspeitos de dois agentes de segurança penitenciária, o acusado foi submetido ao aparelho body scanner, quando então notou-se imagem suspeita em seu abdômen, bem como expeliu os itens apreendidos em situação de isolamento.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários: "(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Portanto, a prova do fato descrito na denúncia e respectiva autoria é robusta. Noutro aspecto, ao contrário do que alega a defesa, não há a necessidade de comprovação do funcionamento dos aparelhos mediante perícia para configuração do delito.

Nesse sentido:

"JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS. PENAL. ART. 349-A CP. INGRESSAR, SEM AUTORIZAÇÃO, EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM APARELHO DE TELEFONIA MÓVEL. CRIME FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. MERA TENTATIVA. INVIABILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 349-A DO CP. NON BIS IN IDEM. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS ADMINISTRATIVAS E PENAL. SENTENÇA MANTIDA (...) 2. Trata-se de crime formal, o qual não exige outros desdobramentos para se caracterizar. O simples fato de o agente adentrar os portões do estabelecimento penal portando aparelho celular, sem autorização legal, já constitui o tipo penal (art. 349-A do CPB), ainda que a eficiência do objeto não tenha sido aferida por laudo técnico-pericial (não confeccionado), e mesmo que o aparelho não chegue ao contato de outros detentos, sendo ainda dispensável a prova de que o aparelho seria usado para fins ilícitos." (APJ 20150110399057. TJDF. 2ª T. Recursal. j. em 15/03/2017. Relator: João Fischer).

Cabe destacar, ainda ao contrário do sustentado pela nobre defesa técnica, que a perícia não afirmou que os telefones celulares eram inaptos à sua finalidade específica de propiciar comunicação.

Tanto assim que, no laudo pericial, a fls. 50, restou expressamente consignado que os aparelhos estavam inoperantes "no momento dos exames". (grifo não é do original).

Ademais, pela própria lógica, é possível afirmar que os aparelhos funcionavam ou poderiam funcionar.

O acusado não se submeteria ao risco de ser capturado em flagrante, ser apenado administrativamente com a grave sanção de regressão de regime e responder a processo criminal, apenas para levar para o interior da unidade prisional telefones ineficazes para comunicação com o mundo externo.

Tampouco há que se falar em crime impossível, sob argumento de que, como todos os detentos são revistados ao entrar ou sair da unidade prisional, o réu não conseguiria introduzir os aparelhos no presídio.

Na verdade, o acusado teria atingido sua finalidade se contasse com a conivência ou negligência dos agentes de segurança penitenciária.

Aliás, a própria experiência contradiz o argumento da defesa, pois se sabe que, constantemente, são encontrados aparelhos da espécie no interior de unidades prisionais.

Não se deve olvidar, ainda, que, em face do elevado número de presos e do reduzido

número de agentes de segurança penitenciária, nem todos aqueles são submetidos ao scanner corporal.

Ainda, em caso análogo, assim se orientou a jurisprudência:

"Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por fragilidade probatória ou, quando não, pelo reconhecimento de crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado pela ré para transportar o entorpecente para o interior do presídio, tendo em vista o procedimento de revista ao qual seria submetida. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação. Eficácia, ademais, do meio empregado pela ré para a prática do tráfico. Reincidência específica, não reconhecida em primeiro grau, bem comprovada nos autos. Recurso ministerial provido, para aumentar as penas, e improvido o apelo defensivo." (TJSP, Apelação n. 0076838-45.2010.8.26.0224, rel.Sérgio Coelho, j. 29/11/2012).

Prosseguindo, a alegação de coação moral irresistível também não pode ser acolhida. A mera alegação de estar sendo coagido, sem outras provas para corroborar sua existência, não é suficiente para formar convicção a respeito.

Conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar cabia à defesa, e dele ela não se desincumbiu.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Art. 33 da Lei nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A coação moral irresistível deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP, pois incumbe à defesa o ônus de provar eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva, tais como a excludente de culpabilidade alegada. A mera alegação não é suficiente para comprovar. (Apelação 0000049-06.2016.8.08.0059 - TJ ES - 1ª Câmara Criminal - Relator: Willian Silva).

Não se pode, é certo, ser insensível ao argumento de que seria praticamente impossível delatar um traficante atuante no interior de unidade prisional, ante os evidentes riscos que tal prática envolveria.

No entanto, a Justiça Criminal não pode se contentar com simples alegação, desacompanhada de substrato probatório mínimo.

No caso concreto, veja-se que o réu declarou ter contraído a dívida no valor de R\$ 850,00, correspondente ao consumo de 85 gramas de maconha, durante o período de pouco mais de um mês, bem como que estava detido no presídio em questão há quase um ano.

Quando questionado como adquiria a droga anteriormente ao período referente à contração do débito, simplesmente disse que o fazia com a ajuda de sua esposa, a qual posteriormente restou impossibilitada de continuar auxiliando-o em razão de ter sofrido ACV e derrame cerebral.

No entanto, nada disso restou provado, ou seja, não se demonstrou que o acusado recebia ajuda financeira da mulher voltada à aquisição de entorpecente, e nem que ela exercia atividade rentável e que deixou de perceber renda em razão daqueles problemas de saúde, igualmente não evidenciados ainda que minimamente.

O acusado também não explicou se exercia ou não trabalho externo e eventualmente por qual razão não efetuou a quitação da dívida através do salário.

Também não vieram para os autos depoimentos de outros presos que, na mesma época, teriam sido submetidos a coação de igual espécie e para o mesmo ou semelhante fim. Logo, pois, a afirmação de que o acusado teria sido coagido moralmente de forma irresistível não pode ser levada a sério.

Por fim, não há que se falar em tentativa, pois o acusado chegou trazendo os telefones celulares até a portaria, dependência esta que já é parte integrante da unidade prisional e situada no interior dela.

Em suma, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixa-se a pena base no mínimo legal, ou seja, três meses de detenção.

O réu é reincidente (fls. 66/67 - artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06; e fls. 67 - artigo 33, caput, Lei n. 11343/2006).

No entanto, em juízo, admitiu ao menos que trazia consigo os telefones celulares ao

ingressar na unidade prisional.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência."

(HC n. 288.910/SP, 6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015).

No caso concreto, no entanto, não se pode determinar pura e simplesmente a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, pois, como visto, esta última é ensejada por duas condenações pretéritas.

Nessa ótica, o melhor a fazer é desconsiderar apenas parcialmente o efeito das condenações anteriores.

Nesse sentido:

"... não há como se operar a compensação integral ante a constatação de múltiplas reincidências. A melhor solução para a hipótese, a fim de não desprestigiar a confissão proporcionada pelos réus, é desconsiderar uma das condenações que caracterizam a reincidência e acrescer à pena patamar de aumento somente pelas condenações restantes." (TJSP, Apelação n. 0023777-06.2010.8.26.0344, rel. Salles Abreu, j. 28/02/2012).

Sendo assim, na segunda fase de aplicação da pena, considerando a reincidência e sua parcial compensação com a atenuante da confissão, eleva-se a pena na proporção de apenas um sexto, resultando em três meses e quinze dias de detenção.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Ante a reincidência, ensejada por duas condenações anteriores, o regime inicial de cumprimento de pena será o semiaberto.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Edson Henrique Dias dos Santos como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a cumprir três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Quanto aos bens apreendidos, são daqueles cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito, desde que mantidos fora de estabelecimento prisional e da posse de presos. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

P.R.I.

Bauru, 16 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA